

1502424-25.2022.8.26.0533
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Santa Bárbara d'Oeste
Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/08/2022
... DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste
Foro de Santa Bárbara d'Oeste
1ª Vara Criminal
Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502424-25.2022.8.26.0533 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502424-25.2022.8.26.0533
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155459/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 25438547 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2155459 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BÁRBARA LIMA DA SILVA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

STEFANY CATARINE DE SOUZA e BÁRBARA LIMA DA SILVA, qualificadas à fl. 38, foram denunciadas e estão sendo processadas como incursas nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque, em princípio, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 17h32min, na Rua do Chumbo, nº

145, na Vila Mollon, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) pedras de "crack", das quais 03 (três) foram vendidas, bem como, tinham em depósito e ocultavam, na Rua do Chumbo, nº 135, 26 (vinte e seis) porções de "crack", consoante auto de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 09/10, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As rés foram notificadas (fls. 150) e apresentaram defesa preliminar (fls.112/113).

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022 (fls. 134). E os réus foram citados (fls. 151).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, sendo as acusadas interrogadas ao final.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência parcial do pedido, absolvendo-se a corré Bárbara. A Defesa, por sua vez, requer a absolvição, pela atuação ilegal dos guardas municipais, bem como por insuficiência de provas.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de nulidade não merece guarida, na medida em que a Guarda Municipal pode atuar ostensivamente, mediante patrulhamentos e rondas, a fim de proteger o patrimônio público, realizando, se o caso, a prisão em flagrante, porquanto se trata de conduta passível a qualquer pessoa. Nesse sentido:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º., do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente (STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min Leonardo de Arruda Raposo j. 05/12/2019)

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda

Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Cívicas). Alegado ausência de interrogatório na Inquérito Policial, que não constitui qualquer eiva. Rejeição. MÉRITO. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a pretendida desclassificação para uso. DOSIMETRIA. Penas preservadas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. DESPROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 1501732-20.2021.8.26.0320; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022, g.n.)

No mérito, a pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls. 38/40, auto de exibição e apreensão de fls.22/23, auto de constatação preliminar de fls. 09/10, laudo de entorpecentes fls. 162/164 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa em relação à acusada Stefany, exclusivamente, havendo dúvidas quanto à corré Bárbara.

Com efeito, Reginaldo Sandrin, guarda municipal, apresentou depoimento no mesmo sentido, afirmando que receberam denúncias de populares acerca de tráfico, informando as vestimentas e características da suspeita, bem como que as drogas eram guardadas em uma caixa de correio, nas proximidades, de forma que passaram a averiguar. Chegando ao local, avistaram 3 (três) pessoas, sendo abordados. Com Stefany foi localizada uma pedra de "crack" na meia, enquanto Wellington portava 3 (três) pedras na carteira, ao passo que, com Barbara, foi localizada certa quantia em dinheiro na mochila. Indagados, todos afirmaram ser usuários. Após diligências, encontraram "kits" com as mesmas drogas na caixa de correios de uma casa abandonada. Wellington, posteriormente, disse que era usuário e havia adquirido as drogas de Stefany, bem como que Barbara guardava o dinheiro. Acrescentou que Stefany era conhecida dos meios policiais. As porções de crack da caixa de correios apresentavam as mesmas características daquelas localizadas com os suspeitos.

Suellen de Oliveira Tomaz, guarda municipal, apresentou relato no mesmo sentido.

A acusada Stefany ficou em silêncio na unidade policial (fl. 13). Interrogada judicialmente, confessou que estava vendendo drogas no dia, bem como que havia guardado as porções na caixa de correios. Negou que Bárbara fosse traficante, mas mera usuária. Acrescentou que forneceu gratuitamente as porções para Wellington, mas não vendeu (mídia).

Por fim, a denunciada Bárbara, na delegacia, declarou que não era traficante, e que estava com suas amigas no local (fl. 11). Em pretório, alegou que havia acabado de sair de um "drive-in", e que estava passando pelo local, quando a corré Stefany a chamou. Disse que o dinheiro encontrado era proveniente de "programas", e que foi até o local para comprar entorpecentes de Stefany. Wellington, que é travesti, já estava nesse lugar (mídia).

Note-se que a confissão de Stefany restou amplamente corroborada pelos demais elementos de convicção amealhados no bojo destes autos, os quais são seguros, harmônicos e coerentes.

Cumpramos ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos guardas municipais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e as rés, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito

do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos guardas e a própria confissão, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância em relação à acusada Stefany.

No que tange à corré Bárbara, por outro lado, ausentes provas seguras, de rigor sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo, até mesmo porque a principal testemunha, Wellington, não foi ouvido em juízo para detalhar a conduta imputada à denunciada, a qual, tanto na fase administrativa como em édito, apresentou a mesma versão de ser unicamente usuária.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes (fls. 54/55), logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa.

Oportuno salientar que, embora não configure reincidência, a condenação por fatos ocorridos anteriormente ao delito narrado, mas com trânsito posterior, é reputada como maus antecedentes. Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado - como ocorre na pecha da reincidência -, senão a simples

prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em julgado após os fatos do segundo processo não elimina, neste último, a consideração do primeiro crime em desabono da pessoa que o praticou. Simplesmente baliza a situação como diversa daquela típica da reincidência. No caso, o trânsito em julgado subsequente nada mais fez que definir uma conduta anterior como criminosa, todavia não foi essa coisa julgada que constituiu a má conduta, evidentemente. Assim, está-se diante um dos espaços normativos próprios da categoria dos maus antecedentes, pois indica o caso em que a pessoa pratica novo crime sabendo que já havia praticado outro anteriormente. Logo, não seria porque o trânsito em julgado desse crime antecedente ocorreu após a prática do segundo crime que, no julgamento deste último, o sujeito será tido como de bons antecedentes quando, efetivamente, não os ostentava. (TJSP; Apelação Criminal 0033114-81.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 502995/MS, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0098424-5, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento 15/08/2019, data da publicação/fonte DJe 23/08/2019)

Não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena-intermediária retorna ao mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, malgrado se trate de ré primária, apresenta maus antecedentes específicos, o que depreende fazer do comércio espúrio seu meio de subsistência, por isso deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica da ré. Colaciona-se a seguinte jurisprudência acerca da matéria:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EResp 1.431.091/SP,

Terceira Seção do C. STJ, Rel. Ministro Felix Fischer, de DJe 01/02/2017, g.n.)

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, tendo em vista o montante de pena imposta, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória, para CONDENAR a ré STEFANY CATARINE DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, bem como para ABSOLVER a denunciada BÁRBARA LIMA DA SILVA da acusação de prática de conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

A ré Stefany não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu presa durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial os maus antecedentes e a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros delitos violentos e causando o vício de inúmeras pessoas, devendo ser recomendada na prisão em que se encontra recolhido. Oficie-se.

Expeça-se alvará de soltura para a corré Bárbara.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que não demonstrada sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome da acusada no rol dos culpados, expedindo-se certidão de honorários ao Advogado nomeado para atuar no feito, no máximo da tabela vigente do convênio OAB/DPE.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto assistida pela DPE/SP.

P.I.C.

De Limeira parra Santa Bárbara d'Oeste, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA